

1517560-41.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196193/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 19149881 - 24º D.P. PONTE RASA, 3268/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2196193

- 24º D.P. PONTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517560-41.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517560-41.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196193/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 19149881 - 24º D.P. PONTE RASA, 3268/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2196193

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL WILSON PEREIRA FERRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

DANIEL WILSON PEREIRA FERRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por uma vez, nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por uma vez, nas penas do artigo 329 do Código Penal e, por duas vezes, nas penas do artigo 129, caput e §2º, da mesma legislação - todos, cumulados com artigo 61, II, j, e na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 21 de julho de 2021, por volta das 00h20, na Avenida São José dos Cordeiros, em São Paulo/SP, DANIEL WILSON PEREIRA FERRO trazia consigo, por ocasião de calamidade pública e para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha e 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, DANIEL WILSON PEREIRA FERRO teria se oposto à execução de ato legal, mediante emprego de violência em face de policiais militares competentes para executá-lo (isto é, dos policiais Isaque Honorio Leite, Raylson da Silva Oliveira, Carlos Alberto Miguel Junior e Pedro Willian Ribeiro Forte).

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, DANIEL WILSON PEREIRA FERRO teria ofendido a integridade e a saúde dos policiais militares Pedro Willian Ribeiro Forte e Carlos Alberto Miguel Junior.

Recebida a denúncia (p. 93), o réu foi citado (p. 117) e apresentou sua resposta à acusação (p. 120/121), que foi rejeitada (p. 127/128).

Durante a instrução processual, foram ouvidas quatro vítimas/testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (p. 134/135 e 137/142).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos moldes da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação da pena base acima do mínimo legal, pela aplicação da agravante do estado de calamidade pública, pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 129, §12º, do Código Penal, pelo afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pela imposição de regime inicial fechado ao tráfico e, semiaberto, aos demais delitos, e pela rejeição da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (p. 138/142).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, por fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal, a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo, a imposição de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de apelar em liberdade (p. 159/164).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 05, pelo boletim de ocorrência de p. 06/10, pelo auto de exibição e apreensão de p. 19, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente de p. 108/111, pelo laudo de exame químico toxicológico de p. 114/116 e pela prova oral coligida aos autos. A conclusão, no entanto, não é a mesma para os crimes de resistência e lesão corporal.

Em juízo, o policial Isaque Honorio Leite asseverou que, na data dos fatos, acompanhado pelo policial Raylson, efetuava patrulhamento, quando avistou dois indivíduos descendo uma rua. Relatou que ambos, avistando a viatura, demonstraram certo nervosismo; com a aproximação, passaram a caminhar para lados diversos; e, proferida ordem para que levantassem as mãos, correram. Explicou que, pelo sentido da viatura, optaram pela perseguição do réu; que, por desconhecer o que os suspeitos carregavam, evitaram se separar; e que, caso manobrassem, poderiam perder ambos. Afirmou que o réu, abordado, apresentou-se "irredutível". Disse que, enquanto se aproximavam, o rapaz colocou a mão na cintura, retirou algo e jogou o objeto para cima; que, neste momento, não conseguiram abordá-lo; que, ao desembarcarem da viatura, Raylson pediu apoio ("na hora que nós desembarcamos da viatura o Raylson pediu apoio, via rede rádio"); que, após a chegada de outra equipe, com seu auxílio, conseguiram imobilizá-lo; que, em seguida, sobre o telhado de uma residência próximo ao local da abordagem, Raylson localizou uma sacola com entorpecentes ("uma porção de maconha e alguns de cocaína (...) a maioria era cocaína"); e que, durante tentativa de imobilização, os policiais "Miguel" e "Willian" se machucaram. Disse não se recordar do número de policiais necessários à detenção do suspeito; que, ao menos, teriam sido "quatro, cinco ou mais"; e que não

estavam conseguindo segurá-lo ("não tava conseguindo, não tava conseguindo segurar ele, tava arrastando todo mundo"). Pela reação, considerou possível que Daniel estivesse sob o efeito de drogas ("droga, bem possível (...) uma pessoa normal é quase impossível fazer o que ele tava fazendo ali"). Afirmou que o acusado, detido, foi colocado no guarda preso e, questionado sobre o que havia dispensado, respondeu não ser nada. Destacou que, no curso da perseguição, em nenhum momento o perderam de vista. Informou que, na ocasião, estava escuro; que, não obstante, conseguiram vê-lo arremessar um objeto; que, para recuperação, "subimos em cima da casa"; que, após buscas, localizaram a sacola; que desconhece se o imóvel era, ou não, habitado; e que, enquanto recuperavam o objeto, não apareceu ninguém. Mais especificamente, disse que "quando começou a procurar lá e achou em cima do telhado a sacola (...) vimos ele jogando pra cima, só não sabia o quê, aí, quando a gente começou a subir em cima dos portão, em cima das casa lá e conseguiu achar a sacola aí". Questionado sobre a falta de autorização dos moradores, disse que, na ocasião, estava próximo à viatura e, por não ter participado das buscas, não pode prestar esclarecimento. Informou que o local do patrulhamento era conhecido como ponto de tráfico. Esclareceu que o montante apreendido estava sob posse do acusado.

Asseverou que Daniel, no pronto-socorro, confessou a traficância, asseverando que, de costume, trabalhava no local e que o fazia por precisar do dinheiro. Questionado sobre quantos metros teriam percorrido até a abordagem, esclareceu que percorreram cerca de 20 ou 30, "no máximo", "foi uma curta distância", e que a venceram em questão de segundo ("coisa de segundos (...) nem um minuto"). Disse que, antes do ocorrido, não havia notado a presença do acusado no entorno. Explicou que, por estar dirigindo, seu parceiro deu início a tentativa de imobilização do acusado; que, logo em seguida, desceu para auxiliá-lo; e que, neste momento, outras viaturas chegaram ("o meu parceiro abordou primeiro, eu na sequência já entrei, como eu tava dirigindo, né... Na hora que ele tentou correr pegou ele, na sequência eu desci para tentar imobilizá-lo, nesse momento as viaturas chegaram"). Afirmou que "praticamente encostou nosso pelotão... porque encostou a viatura do soldado Willian, do soldado Miguel, encostou todos, veio viatura de outra companhia também, porque foi apoio via rádio, então começou a encostar um monte de viatura lá (...) umas seis viatura, não recordo". Disse que, iniciada abordagem, após alguns minutos chegou a viatura de Miguel e Willian; que seus ocupantes os auxiliaram a colocar o réu no guarda preso; e que, depois, estando o réu contido, começaram a chegar as demais viaturas. Confirmou que, na ocasião, carregavam "spray de pimenta ou algo do gênero". Questionado sobre a dinâmica da abordagem, disse que "é impossível explicar isso (...) a gente tentava deter da forma que tinha porque, estávamos lá em quatro, cinco, policiais e não tava conseguindo segurar ele, um segurava no braço, outro na perna...o mínimo que ele conseguia se soltar ele batia". Questionado sobre quem foi o responsável pela revista pessoal, disse não se recordar.

O policial Raylson da Silva Oliveira disse que, por ocasião dos fatos, efetuava patrulhamento, quando percebeu dois indivíduos empreendendo fuga a equipe; que, tendo os suspeitos tomado direções opostas, não teve meios de perseguir ambos; e que, perseguindo o acusado, em nenhum momento o perdeu de vista. Relatou que Daniel, durante a perseguição, retirou uma sacola da cintura e a jogou para cima de um telhado; que, intentada sua contenção, o rapaz, "muito nervoso, começou a trocar socos com a equipe", momento em que solicitaram apoio; que, após chegada do apoio e detenção do acusado, revistando o telhado, localizaram os entorpecentes ("maconha e cocaína, se não me engano (...) quantidade pequena"); e que o acusado, questionado, negou que a droga lhe pertencesse. Explicou que, na ocasião, era o motorista da viatura; que, para recuperação da droga, subiu no portão da casa ao lado e localizou os entorpecentes logo acima, no telhado; e que, por estar de noite e o telhado ser de fácil acesso, não pediu autorização ao proprietário. Questionado, disse não se recordar da iluminação da via. Informou que o fato teria ocorrido próximo a uma praça; que, até certo ponto, o perseguiram de viatura e, após, a pé ("depois agente teve que correr com ele, à pé, só que foi logo em seguida não foi nem questão de cinco, dez metros, a gente conseguiu conter ele"); e que, no momento em que visualizaram o arremesso da droga, estavam a pé. Declarou não se recordar

se, com o réu, foi encontrado algo. Disse que, após a abordagem, todos estavam com arranhões, mas o ferimento mais grave era o do policial que machucou o dedo. Questionado sobre o motivo pelo qual foram necessários vários policiais para conter o acusado, disse não saber explicar. Especulou que Daniel, talvez, estivesse sob o efeito de drogas e esclareceu que “a gente tava em 04 (quatro) policiais ali e não conseguia, não tava conseguindo deter ele, tava difícil”. Questionado sobre o motivo pelo qual optaram pela perseguição do réu, respondeu “porque ele era o mais próximo (...) eu acho que o outro tinha corrido mais”. Afirmou somente ter avistado a sacola no momento em que o acusado a retirou da cintura. Questionado se, no hospital, o réu teria fornecido algum esclarecimento sobre a sacola, disse que não. Confrontado com a alegação de seu parceiro em contrário, disse que devido a divisão de funções (motorista e encarregado), podem, em algum momento, ter ficado separados, para que vigiasse a viatura. Questionado se o local seria ponto de tráfico, informou que, nas proximidades, há uma favela; que desconhece se, ali, funcionava um ponto de venda de drogas; e que, dentre os policiais de sua companhia, é o que tem menos tempo na área. Questionado sobre as circunstâncias da abordagem, informou que desembarcou do veículo ao mesmo tempo que seu parceiro; que ambos iniciaram, juntos, a tentativa de abordagem; que “agente pediu pra ele parar, só que não parou né, e aí foi onde a gente teve que descer ele, conter ele, agente colocou ele, consegui conter ele na parte do chão, só que aí, depois, ele começou a se debater pra cima da equipe, foi onde agente precisou solicitar apoio”; que, somente com a chega das viaturas de apoio, o algemaram; que, em suma, levaram o acusado ao solo e, enquanto ele se debatia, um dos dois retornou à viatura e solicitou apoio; que, na ocasião, dispunham de teaser e de spray de pimenta; e que, somente após a chegada do apoio, pessoa que não se recorda fez uso da arma não letal (“no caso foi usado na segunda vez, na hora que chegou a viatura no apoio (...) por quem eu não me recordo”). Questionado sobre qual dos instrumentos teria sido utilizado, disse “não me recordo se foi usado na ocorrência, porque se não a gente teria que ter colocado no BO”. Questionado sobre o número de policiais, disse “quando agente solicita apoio, vem muita viatura né, eu não consegui contar, porque vem muita (...) o que eu me recordo era dos policiais que estava no BO (...) que foram os que conteram ele (...) mais de cinco ou seis viaturas, foi muita viatura (...) uma média de doze policiais”. Asseverou que, por conta do horário e região, nenhum morador deixou a residência. Questionado sobre as características do imóvel em cujo portão se apoiou, disse apenas se recordar que era um portão “de lança”. Informou que estavam todos juntos no momento em que os policiais se feriram; que, ao que se recorda, o acusado teria desferido um chute contra a mão daquele que restou lesionado; e que, após o fato, este policial, por conta do dedo, foi afastado do serviço. Questionado sobre a característica da sacola, respondeu que era uma sacola plástica, de cor que não se recorda. Disse que, após abordagem, encaminharam-se ao pronto socorro e, dali, foram até a delegacia; que decidiram, por conta, encaminhar o acusado ao hospital; que a decisão foi motivada pelo fato do réu e de um policial estarem machucados; que, por terem entrado em vias de fato, Daniel machucou-se; que os machucados foram produzidos em auto defesa; e que, ao que se recorda, o réu ostentava hematomas na cabeça.

O policial Carlos Alberto Miguel Junior aduziu que, no curso de um patrulhamento, recebeu pedido de apoio emitido, via rádio, pelos policiais Isaque e Railson; que, chegando ao local, percebeu que ambos tentavam conter um indivíduo; que o acusado, na ocasião, “tava resistindo, dando soco, chute”; que, tendo se aproximado, recebeu um chute, que o deixou com uma luxação na mão, e um soco no rosto; que outras viaturas compareceram ao local e, a medida que chegavam, passaram a auxiliar a captura; e que, conseguindo segurá-lo, o transportaram à viatura. Questionado sobre o número de policiais necessários à contenção do acusado, respondeu “uns seis polícia, não me lembro”; que nem todos tentaram contê-lo, havendo aqueles que ficaram na segurança; e que não se recorda do número daqueles que auxiliaram na contenção. Negou que, por força da lesão, houvesse deixado de trabalhar ou, ainda, se submetido à perícia no IML. Informou ter passado por atendimento, apenas, em pronto-socorro. Questionado se teriam sido os primeiros a prestar apoio, disse que não se recorda. Questionado sobre a posição dos policiais que iniciaram a abordagem

quando de sua chegada ao local, disse que não se recorda. Informou que, ali, seu parceiro, "Paulo Henrique" permaneceu na segurança e que o policial Pedro é de outra viatura. Questionado se seu parceiro teria ingressado no entrevero, disse "não, meu companheiro não". Questionado se, após a contenção, procederam revista pessoal, disse que não se recorda, que apenas prestou apoio à contenção e, após, encaminhou-se ao pronto socorro, não sabendo informar o que ocorreu com o rapaz. Questionado sobre o motivo pelo qual não foi ao IML, respondeu "porque eu não quis".

Pedro Willian Ribeiro Forte informou que, por ocasião dos fatos, os ocupantes de determinada viatura solicitaram apoio; que, comparecendo ao local, deparou-se com uma "vias de fato" entre os policiais e o indivíduo; que, com a pretensão de conter o acusado, tentou segurar sua perna e, neste momento, levou um chute na mão; que, por força do chute, fraturou o osso da mão direita; e que, após, contê-lo, seguiram ao pronto socorro e, depois, a delegacia ("mesmo com a mão quebrada a gente conseguiu contê-lo, aí foi PS, DP, aí eu não vi o desfecho da ocorrência, como a ocorrência não era minha eu continuei o patrulhamento e a equipe que tava... que deteve ele, prosseguiu com a ocorrência no DP"). Informou nada saber acerca do tráfico de drogas. Disse que, devido a lesão, foi afastado por 15 (quinze) dias e, após, tendo solicitado férias, prosseguiu com o repouso e com o tratamento. Afirmou reconhecer o réu como sendo a pessoa que o agrediu. Negou que, ao chegar, o réu estivesse algemado. Asseverou que tiveram dificuldade para contê-lo, tendo sido necessário o concurso de 04 (quatro) ou 05 (cinco) policiais. Confirmou que portava instrumentos não letais e que não fez uso de qualquer deles. Questionado se teria localizado ou, ao menos, visualizado alguma "bolsa", disse que não. Informou que a equipe que solicitou o apoio realizou revista pessoal; que não acompanhou o procedimento; e que não sabe qual dos policiais efetuou a revista. Negou ter se submetido a exame de corpo de delito e justificou a omissão dizendo "porque eu não quis ir". Negou ter acompanhado o acusado até a delegacia. Questionado se, ao sair, Daniel apresentava lesão, respondeu "não vislumbrei".

Interrogado, o réu Daniel Wilson Pereira Ferro disse que, por ocasião dos fatos, estava na residência de sua namorada, quando decidiu retornar ao seu domicílio; que, na rua, avistou um conhecido e, pelo horário avançado, decidiu retornar em sua companhia; que, na metade do caminho, o rapaz, avistando a viatura, lhe disse "corre"; que, "por impulso", começou a correr; que cada um correu para um lado e, tendo sido perseguido, reputou que inexistia motivo para fugir e parou. Asseverou que, os policiais que depuseram por último, se aproximando, passaram a agredi-lo ("já chegaram colocando a mão em mim, me agredindo, um deles me deu uma coronhada na cabeça, na parte aqui, atrás aqui assim, que eu tomei até uns pontos"); que, após a agressão, caiu e foi algemado; que, questionado sobre o paradeiro do rapaz que o acompanhava, não soube prestar esclarecimento; que, após, foi conduzido à viatura e, com a chegada de novos policiais, removido do compartimento e, novamente, interrogado; que foi agredido e, em um momento de "desespero", passou a se debater; que os policiais, em revide, o viraram de ponta cabeça e chutaram seu rosto; e que, buscando forçar uma delação, ameaçaram sufocá-lo com uma sacola e, após, imputar-lhe a ocorrência. Negou que estivesse em posse da sacola contendo entorpecentes ou, ainda, que houvesse visto seu acompanhante arremessa-la. Negou, ainda, prisão anterior. Disse que, uma vez algemado, os policiais não mais soltaram as algemas; que suas mãos ficaram para trás; que não houve, pela polícia, emprego de arma não letal; que não faz uso de droga; que estava em posse de R\$ 12,00 ou R\$15,00, para pagamento de condução; que trabalha como autônomo, vendendo roupas no Centro; e que responde processo por receptação. Observou que, ao se debater, pode ter acertado algum dos policiais, contudo, não se recorda de tê-los agredido. Confirmou ter sido conduzido ao hospital e, ali, sido atendido e recebido sutura no ferimento causado pela coronhada. Pontuou que, no local, um dos policiais manifestou pretensão de passar por consulta, por ter tido a mão chutada. Negou que, antes dos fatos, conhecesse os policiais ou, ainda, que houvesse feito algo que pudesse desagradá-los. Disse não saber se o outro rapaz os conhecia.

Pois bem.

Sob o crivo do contraditório judicial, os policiais militares que efetuaram a

prisão em flagrante do acusado foram formalmente ouvidos e, nos pontos que convergiram, reiteraram a narrativa anterior. Segundo afirmaram, nas circunstâncias descritas na denúncia, Isaque e Rayson efetuavam patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos - o acusado e um segundo rapaz - em atitude suspeita; que, ao se aproximarem, ambos correram; que, tendo seguido no encalço do réu, avistaram o momento em que ele arremessou uma sacola para o alto; que, realizada a abordagem, houve resistência, contida mediante concurso de policiais que atenderam pedido de apoio (dentre os quais, inclusive, Carlos e Pedro); que, resistindo, Daniel ofendeu a integridade física de ambos; e que, ao recuperar a sacola, localizaram em seu interior os entorpecentes apreendidos.

Ante o relato, iniciando a análise pelo crime de tráfico de drogas, cumpre acrescentar que o réu, confirmando ter empreendido fuga, deixou de esclarecer satisfatoriamente sua motivação. Em juízo, suscitando versão pouco crível, asseverou ter fugido por orientação de mero conhecido. Após, infirmando o caráter instintivo imputado ao comportamento, admitiu adoção de providência tendente a reduzir a possibilidade de abordagem - isto é, a opção por fuga em direções opostas.

Perante a conjuntura, não observada, na narrativa relativa à dispensa e localização dos entorpecentes, divergência apta a infirmar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, forçoso admitir as circunstâncias que motivaram o flagrante, a quantidade, variedade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, sua compatibilidade com a comercialização espúria e a insubsistência das escusas do acusado, como provas suficientes de subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, dos relatos relativos aos crimes de resistência e lesão corporal, extraem-se discrepâncias que, confrontadas, inviabilizam a condenação do acusado. Em solo policial, Isaque e Rayson declararam que ao ingressarem em determinada via, avistaram dois indivíduos que, percebendo a presença da viatura, tentaram empreender fuga; que, "de imediato" (grifei) solicitaram apoio; que, após 20 metros de perseguição "logram abordar o indivíduo, que dispensou uma sacola plástica"; e que, após emprego de resistência, servindo-se de auxílio prestado por Carlo Alberto e Pedro William, procederam a detenção do suspeito e localizaram, em sua posse, R\$ 12,00 e, no interior sacola dispensada, os entorpecentes (p. 11/12). Carlos e Pedro, por sua vez, em consonância, relataram que, pela rede rádio, foram cientificados de que "dois indivíduos tentavam se evadir da VTR"; e que, prestando auxílio, foram lesionados (p. 13/14).

Em cotejo, do relato posterior de Isaque colhe-se a informação de que, naquela noite, tendo os policiais optado pela perseguição exclusiva de Daniel e, para captura, encetado perseguição por cerca de 20 (vinte) ou 30 (trinta) metros, Rayson, desembarcando da viatura, solicitou apoio via rádio e iniciou tentativa abordagem que, apenas com o concurso do apoio, foi concluída; e, daquele prestado por Rayson, diversamente, a informação de que, após desistência do outro suspeito, aproximação, desembarque, descarte da sacola e tentativa de abordagem do réu, com sua contenção em solo, tendo Daniel começado a se debater, um dos agentes retornou à viatura e, apenas então, solicitou apoio.

As duas últimas versões, obviamente, não apenas divergem do relato inicial, que noticia um pedido imediato para auxílio na detenção de dois suspeitos, com posterior abordagem e subsequente descarte, como, ainda, divergindo entre si, não esclarecem, adequadamente, o momento em que encaminhada solicitação e, no caso específico de Isaque, as razões que motivaram sua formulação.

Em relação aos ferimentos ostentados pelo acusado, laudo de lesão corporal cautelar, em ponto corroborado pela fotografia coligida na p. 31 e, ainda, pelo depoimento do policial Railson, atestou que Daniel, após os fatos, ostentava "couro cabeludo sob enfaixamento" e "hematoma infraorbitário direito" (p. 102/103).

Não obstante, colhida em audiência a informação de que, iniciada a abordagem, tendo Railson obtido sucesso em "conter" Daniel "na parte do chão", o rapaz teria começado a se debater (depoimento de Railson) e de que os esforços, a partir de então, teriam se concentrado em segurar seu membros, para imobilização (depoimento de Isaque), causa estranheza a constatação de, ao final da ação, Daniel apenas

ostentava ferimento na região da cabeça.

As descrições da dinâmica da abordagem foram, todas, insatisfatórias.

Não fosse suficiente, há a contradição de Raylson, que ora confirmou a utilização de instrumento não letal e, no momento seguinte, negou.

Perante este quadro, subsistindo dúvida razoável quanto ao desenrolar dos fatos que ensejaram as lesões verificadas, o réu não pode ser responsabilizado pelos delitos de resistência e lesão corporal. Segundo a jurisprudência: "A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se". (RT 714/357 e 358); e, ainda, "Sentença Absolutória - Para a condenação do réu a prova há de ser plena, convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 386, inciso VI do CPP"

(JTACrim, 72/26, Rel. Álvaro Cury).

Não se está afirmando a inocência do réu, nem mesmo a inocorrência dos fatos, mas, apenas, que estes não foram devidamente provados em juízo. Subsistindo dúvida razoável sobre a procedência da imputação, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, inviável, nesse ponto, a condenação do réu.

Devidamente delimitada sua responsabilidade, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n.11.343/06, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (proc 1501237-10.2021.8.26.0050 - p. 46/47 e <https://esaj.tjsp.jus.br/>), razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Segundo jurisprudência, eventual condenação por fato anterior ao que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ, HC n. 210.787/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013).

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço, apenas, a presença da atenuante da menoridade relativa (p. 16) e obtenho a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observado o disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, nada indica que o réu tenha se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática do crime, não tendo a agravante imputada aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Quatro indivíduos se aproximaram da vítima a bordo de um veículo, sendo que três deles desembarcaram e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta do ofendido. Menos de duas horas após a prática criminosa, os réus foram localizados na condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa, sendo reconhecidos pela vítima e detidos em poder do instrumento bélico e do aparelho celular subtraído. A motocicleta foi encontrada estacionada nas proximidades. Autoria e materialidade comprovadas. Prova oral satisfatória à confirmação dos fatos. No entanto, conquanto o concurso de agentes esteja bem delineado pelo acervo probatório, tratando-se da inequívoca participação de quatro indivíduos, a majorante do emprego de arma de fogo deve ser excluída, porquanto, consoante laudo pericial de fls. 179/182, a arma era absolutamente inapta ao disparo ("devido à ausência do pino percutor"). Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais. Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro:

08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos

continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor. PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - REGIME PRISIONAL FECHADO - PEDIDO DE ABRANDAMENTO - REU REINCIDENTE e COM MAUS ANTECEDENTES - REGIME FECHADO IMPRESCINDÍVEL - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

Passando à terceira fase, a existência de condenação criminal definitiva obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Os requisitos previstos no dispositivo legal são cumulativos e ausência de qualquer deles impede a incidência do benefício.

Nesse sentido: "Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui maus antecedentes" (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16.05.2019).

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. O fato do réu, por fato praticado em 30.10.2020, ostentar maus antecedentes e, após sua consumação, ter cometido delito hediondo, mediante porte, inclusive, de 64 (sessenta e quatro) porções de entorpecentes de alta potencialidade lesiva, torna forçoso o reconhecimento de que a fixação de regime mais brando, em seu caso, não seria suficiente à prevenção e repressão da conduta.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, a fixação do regime inicial não encontra fundamento apenas no quantum de pena privativa de liberdade, mas, principalmente, nas condições subjetivas do réu. Ademais, o período de prisão cautelar cumprido até o momento não basta para qualquer abrandamento.

O réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

A) CONDENO o réu DANIEL WILSON PEREIRA FERRO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal; e

B) ABSOLVO o réu DANIEL WILSON PEREIRA FERRO das imputações dos crimes previstos nos artigos 329 e 129, caput e §2º, do Código Penal, e assim o faço, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Após ser preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução e não houve qualquer alteração da situação fática que determinou a conversão em prisão preventiva. Ademais, dispondo de condenação anterior, o cometimento de novo delito evidencia o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Recomendo o réu a estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos (salvo pequena amostra, que poderá servir como contraprova).

Com o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA